

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第二十三講 解釋要旨
不受軍事審判
& 居住遷徙自由

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈軍事審判〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
262 (79.07.06)	監察院對軍人提出彈劾案時，應移送公務員懲戒委員會審議。至軍人之過犯，除上述彈劾外，其懲罰仍依陸海空軍懲罰法行之。	§9	[軍人懲罰與法官保留] Q 軍人過犯何以不適用「法官保留」原則？
272 (80.01.18)	戒嚴法第八條、第九條規定，非現役軍人得由軍事機關審判，為憲法承認戒嚴制度之例外。解嚴後，依同法第十條規定，對於上述軍事機關之判決，得於解嚴之翌日起依法上訴，符合首開憲法規定之意旨。惟動員戡亂時期國家安全法第九條第二款前段規定，戒嚴時期戒嚴地區地域內經軍事審判之非現役軍人刑事案件已確定者，於戒嚴後不得向該管法院上訴或抗告，係基於此次戒嚴與解嚴時間相隔三十餘年之特殊情況，並謀裁判之安定而設，亦為維持社會秩序所必要。且對有再審或非常上訴原因者，仍許依法聲請再審或非常上訴，已能兼顧人民權利，與憲法尚無牴觸。至戒嚴非屬於此次特殊情況者，無本解釋之適用，合併指明。 ① 76/07/15 宣布解嚴；戒嚴法迄未修正。	§9； 動員戡亂時期 國家安全法 §9-II [釋 436]	[戒嚴法與非現役軍人不受軍事審判] [非現役軍人受軍事審判之救濟限制]

22 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
272 (續)	① 81/07/29「動員戡亂時期國家安全法」更名為「國家安全法」，系爭條文未修正。		
298 (81.06.12)	憲法第七十七條規定，公務員之懲戒屬司法權掌理事項。此項懲戒得視其性質於合理範圍內以法律規定尤其長官為之。	§77	[公務員懲戒與法官保留]
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
436 (86.10.03)	憲法第九條規定：「人民除現役軍人外，不受軍事審判」，乃因現役軍人負有保衛國家之特別義務，基於國家安全與軍事需要，對其犯罪行為得設軍事審判之特別訴訟程序，非謂軍事審判機關對於軍人之犯罪有專屬之審判權。軍事審判亦為國家刑罰權，其發動與運作，必須符合正當法律程序之最低要求，包括獨立、公正之審判機關與程序，並不得違背憲法第七十七條、第八十條等有關司法權建制之憲政原理；規定軍事審判程序之法律涉及軍人權利之限制者，亦應遵守憲法第二十三條之比例原則。本於憲法保障人身自由、人民訴訟權利及第七十七條之意旨，在平時經終審軍事審判機關宣告有期徒刑以上之案件，應許被告直接向普通法院以判決違背法令為理由請求救濟。 ① 88/10/02 軍事審判法修正，詳本講講綱。	§§8, 9, 16, 23, 77； [釋 272]	[軍事審判_正當程序（程序正當）] Q 何以僅須符合正當程序之「最低要求」？ Q 憲法第九條為第八條之特別規定？ Q 釋憲者得逕行諭知修法之具體內容（正當程序之最低限度）？其憲法之依據為何？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
436 (續)	〈陳計男大法官協同意見書〉 關於現役軍人對於「受有期徒刑以上刑之宣告」之請求普通法院審判權之宣示，應非絕對劃分軍法、司法終審審判之唯一標準。隨軍事審判制度之改變與進步，並非不可改變其區分標準，諸如考慮將軍事審判之最終上訴規定為可由軍事被告選擇上訴於終審軍事審判機關或上訴於相當終審之普通法院，但選擇上訴最終軍事審判機關者，除死刑或無期徒刑者外，即不得再請求普通法院審判。		[軍審法修正諭知] Q 本件多數意見何以諭知「受有期徒刑以上刑之宣告」應許上訴普通法院？
	〈董翔飛大法官協同意見書〉 軍事審判既屬司法權之一種，自亦應移由司法院所屬各級法院掌理，方符憲法第七十七條之意旨。行政院為國家最高行政機關，國防部隸屬於行政院之下，屬行政體系之一環。軍事審判法第十一條規定「國防部為最高軍事審判機關」，掌理司法權之軍事審判，破壞國家機關權限之分際，嚴重違背權力分立原則，與憲法第七條、第八條、第九條、第十六條及第七十七條之意旨均有未合應定期使其失效。		[軍事法院應改隸司法院] Q 所謂「憲法第九條為第八條之特別規定」，係指「正當程序」（審判程序）之例外？抑或「法院組織」（隸屬）之例外？
	〈王澤鑑大法官協同意見書〉 在平時軍事審判機關宣告有期徒刑以上之案件，應許被告直接向普通法院以判決違背法令為由請		[軍審制度之立法裁量空間] Q 「軍事審判之司法

22 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
436 (續)	求救濟，僅屬階段性的軍事審判建制，而非將軍事審判之司法化固定於此規範模式。		化」屬「司法」抑或「立法」之職權？
	〈孫森焱大法官部份不同意見書〉 若改進之目標達成，其終審軍法裁判經宣告有期徒刑以上之刑之案件，是否仍應「全部」許被告直接向普通法院之法律審請求救濟，方屬合憲？		[軍審法修正諭知]
	〈林永謀大法官部份不同意見書〉 本解釋示明經終審軍事審判機關宣告有期徒刑以上之案件應許被告向普通法院請求救濟，並著立法機關應就審級制度為配合，根本即侵及立法者職權。		[軍審法修正諭知] Q 何謂「根本即侵及立法者職權」？
新制（92.10～：釋字 567～）			
704 (101.11.16)	陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第七條，關於後備役軍官志願入營服役期滿而志願繼續服現役者，應依志願留營規定辦理，其中應經之核准程序規定，適用於經考試院特種考試及格志願入營服役，而尚未經核准得服現役至最大年限（齡）之軍事審判官部分，以及陸海空軍軍官士官服役條例第十七條關於服現役期滿予以解除召集之規定，適用於上開情形部分，與司法權建制之審判獨立憲政原理及憲法第十六條保障人民訴訟權之意旨不符，應自本解釋公布之日起至遲於屆滿二年時，對於上開類型軍事審判官不予適用。	§§ 9, 16, 80 [釋 436]	[申請志願留營軍事審判官之身分保障] Q 系爭二規定，如何違憲？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
704 (續)	〈湯德宗大法官協同意見書〉 將軍事審判完全改隸於司法院，並使軍法官概為憲法第八十條（獨立審判）與第八十一條（終身職保障）之文職法官，要非憲法所不許。惟「非憲法所不許」不等於「憲法所要求」者，在本解釋所釋示之「審判獨立」所要求之最低限度以外（之上），是否及如何謀求制度改進，原有諸多選項，乃民選政治部門應為之抉擇，並應就其抉擇向選民負起政治責任。釋憲機關守護憲法則非謹守憲法分際，無以維持審判獨立。軍事審判官固不以終身職為必要，惟仍應享有適當之身分保障，非受刑事或懲戒處分、監護宣告，或有法律列舉之不適任審判之原因，並經正當法律程序，不得免職。		

〈居住遷徙自由〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
265 (79.10.05)	動員戡亂時期國家安全法 §3-I-(2)之入境限制，乃維持社會秩序所必要，與憲法並無抵觸。	§10 [釋 345]	[入出境限制] Cf. 釋字 558
345 (83.05.06)	行政院發布之「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境實施辦法」，並未逾越稅捐稽徵法授權之目的及範圍，且其 §5 有應即解除出境限制之規定，已兼顧納稅義務人之權益，係為確保稅收，增進公共利益所必要，與憲法尚無抵觸。	§10 [釋 265]	[欠稅人限制出境] Q 為確保稅收可限制人民出境，為確保私人履行債務則不可？
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
398 (85.03.22)	農會由居住農會組織區域內，實際從事農業之人依法參加為會員，其資格認定以「居住農會組織區域內」及「實際從事農業」為要件。農會法 §18-(4) 規定農會會員住址遷離原農會組織區域者為出會之原因，係屬法律效果之當然規定，與憲法 §§7, 10 亦無抵觸。	§10	[遷徙自由與農會會籍] Ω 會籍限制 ≠ 居住限制
443 (86.12.26)	憲法 §10 規定人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有任意移居或旅行各地之權利。	§10 [釋 454]	[居住遷徙意義] Q 所謂「各地」，包括外國？
	〈解釋理由書〉 憲法 §10 規定人民有居住及遷徙之自由，係指人民有選擇其居住		Q 「營私人生活不受干預之自由」=「隱

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
443 (續)	處所，營私人生活不受干預之自由，且有得依個人意願自由遷徙或旅居各地之權利。		私」？ Q 居住遷徙自由亦「隱私」之一種？
	限制憲法 §10 保障任意移居或旅行各地之權利，必須符合憲法 §23 所定必要程度，並以法律定之或經立法機關明確授權由行政機關以命令訂定。		[層級化法律保留原則] Cf. 釋字 443
	行政院發布之徵兵規則，委由內政部訂定役男出境處理辦法，係對人民居住遷徙自由之重大限制，欠缺法律授權之依據，應自本解釋公布日起至遲於屆滿六個月時，失其效力。		[法律保留原則]
454 (87.05.22)	憲法 §10 規定人民有居住遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利。	§10 [釋 443]	[居住遷徙意義]
	行政院修正核定之「國人入境短期停留長期居留及戶籍登記作業要點」第七點第一項第三款及第二項之相關規定，係為執行國家安全法等特別法所必要者外，其餘各款及第二項戶籍登記之相關規定、第三項關於限期離境之規定，均與憲法 §10 意旨不符。		[國民入出境限制]
497 (88.12.03)	「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」及「大陸地區人民在臺灣地區定居或居留許可辦法」，明定大陸地區人民進入臺灣地區之資格要件、許可程序及停留期限，係在確保臺灣地區安全與民眾福祉，符合臺灣地區與大陸地	§10； 增修 §11 [釋 710]	[大陸地區人民遷徙自由之限制] Q 本件採何種審查基準？何故？

23 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
497 (續)	區人民關係條例之立法意旨，尙未逾越母法之授權範圍，為維持社會秩序或增進公共利益所必要，與憲法增修條文第十條（現改列為第十一條）無違，於憲法第二十三條之規定亦無牴觸。		
517 (89.11.10)	妨害兵役治罪條例 §11-I-(3) 規定後備軍人居住處所遷移，無故不依規定申報者，即處以刑事罰，係為確保國防兵員召集之有效實現、維護後備軍人召集制度所必要。其僅課予後備軍人申報義務，並未限制其居住遷徙之自由，與憲法 §10 之規定尙無違背。	§10	[遷徙自由] Ω 強制申報 ≠ 禁止遷徙 Cf. 釋字 398
542 (91.04.04)	「翡翠水庫集水區石碇鄉碧山、永安、格頭三村遷村作業實施計畫」雖對人民居住遷徙自由有所限制，惟計畫遷村之手段與水資源之保護目的間尙符合比例原則，要難謂其有違憲法第十條之規定。	§10	[遷徙自由] Q 強制遷村（手段）何以為「保護水源」（目的）所必要？有無配套安置措施，應併列入「比例原則」之考量？ Q 本件採審查基準？
558 (92.04.08)	憲法第十條規定人民有居住、遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境之權利。人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。於臺灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可，惟為維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並非不得限制，但須符合憲法第二十三條之比例原則，並以法律定之。	§§10, 23； '00 增修 §11 [釋 265] [釋 454] [釋 497]	[國民入出境限制] Q 國民參與國際恐怖組織者，得限制其返國？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
558 (續)	動員戡亂時期國家安全法…第三條第二項第二款係為因應當時國家情勢所為之規定，適用於動員戡亂時期，雖與憲法尚無牴觸(參照本院釋字第二六五號解釋)，惟中華民國八十一年修正後之國家安全法第三條第一項仍泛指人民入出境均應經主管機關之許可，未區分國民是否於臺灣地區設有住所而有戶籍，一律非經許可不得入境，並對未經許可入境者，予以刑罰制裁(參照該法第六條)，違反憲法第二十三條規定之比例原則，侵害國民得隨時返回本國之自由。國家安全法上揭規定，與首開解釋意旨不符部分，應自立法機關基於裁量權限，專就入出境所制定之法律相關規定施行時起，不予適用。		[國民返國之自由]
	〈劉鐵錚大法官不同意見書〉 本號解釋對早已部分不適用之舊法(國家安全法第三條第一項)，固有事後澄清及宣告部分違憲之作用，但重要的是，對現行適用之新法(入出國及移民法第五條第一項但書)，則有造成如何適用法律及是否增加住所要件之困惑，至於其肯定立法者得以住所決定對國民入出境是否採取許可制之標準，本席尤難同意。		Q 其與多數意見之根本差別為何？
699 (101.05.18)	〈湯德宗大法官部分協同暨部分不同意見書〉 「行動自由」在我國憲法上的依據是第十條所稱「居住及遷徙之		Q 駕車自由屬「遷徙自由」(行動自由)或

23 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
699 (續)	自由」，而其核心意涵則來自憲法第八條的「人身自由」。亦即，狹義的「人身自由」固指憲法第八條所規定的「人身安全」（即人民身體應有免於遭非法逮捕、拘禁、審問、處罰之自由）；廣義的「人身自由」則以「人身安全」為基礎，擴及於憲法第十條所規定的「居住及遷徙之自由」，再擴及於「在不妨害社會秩序公共利益之前提下，人民依其意志作為或不作為之一般行為自由」（屬於憲法第二十二條所保障的概括基本權）。三者的關係猶如同心圓般，乃由內（核心）而外（外沿），漸次展開。		「一般行為自由」？
710 (102/07/05)	合法入境之大陸地區人民應享有憲法所保障之遷徙自由。 （詳●22講 解釋要旨）		

《對話憲法・憲法對話》2016